

1500153-61.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HEBER GUALBERTO MENDONCA

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... Tribunal Federal (STF) entendeu que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. A discussão ocorreu no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, que foi deferido por maioria dos votos:

"O crime de tráfico privilegiado de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

4ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500153-61.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500153-61.2021.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON ADRIANO PIRES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HEBER GUALBERTO MENDONCA

I - Do Relatório

ANDERSON ADRIANO PIRES, qualificado à fl. 7, foi denunciado e processado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, em tese, no dia 22 de janeiro de 2021, por volta das 23h20, na residência situada na Rua Antônio Raposo, nº 368, Vila Nova, na cidade de Braúna e Comarca de Penápolis trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, drogas, consistentes em 45 microtubos plásticos do tipo eppendorf contendo cocaína, totalizando 32,10 gramas (trinta e dois gramas e dez centigramas); mais 16 porções de maconha, totalizando 211,09 gramas (duzentos e onze gramas e nove centigramas).

Segundo consta da denúncia, o imputado resolveu praticar o tráfico de drogas nesta cidade, mormente no local do fato e para tanto trazia consigo e guardava as drogas apreendidas em seu poder, consistente em maconha e cocaína.

Naquele dia, hora e local dos fatos, ANDERSON, sua namorada Brenda e uma vizinha estavam sentados na calçada em frente à residência acima descrita, oportunidade em que os policiais militares que realizavam patrulhamento, avistaram ANDERSON, o qual

correu para o interior da residência.

Então, os agentes de segurança, que já possuíam informações sobre o tráfico por parte do denunciado e diante da desobediência da ordem de parada, adentraram na residência e abordaram o denunciado.

Durante a abordagem, em busca pessoal, os policiais localizaram junto ao denunciado, uma porção de maconha.

Indagado sobre a existência de drogas no interior da residência, ANDERSON informou os locais que havia drogas. Assim, os policiais localizaram embaixo da cama uma sacola plástica com 45 microtubos de eppendorf contendo de cocaína e outra dentro da geladeira com 14 porções de maconha.

No quarto do denunciado foram encontrados mais 01 porção de maconha sobre uma mesinha, papel de seda, tesoura, faca e a quantia de R\$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais) em cédulas diversas.

Notificado (fl. 204), o réu apresentou defesa preliminar (fls. 264/265).

A denúncia foi recebida no dia 18.1.2022 (fls. 266/271).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns (fls. 301/302), sendo o réu interrogado ao final (fl. 300).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia (fls. 297/298). A Defesa, por sua vez, requereu aplicação da pena no mínimo legal, considerando a confissão espontânea e a redução do §4º do artigo 33 da LAD (fls. 303/307).

II - Da Fundamentação

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou plenamente comprovada pelo: i) auto de prisão em flagrante (fl. 1); ii) boletim de ocorrência (fls. 2/4); iii) auto de exibição e apreensão (fls. 8/9); iv) laudo dos objetos do crime (tesoura, faca e papel de seda - fls. 127/131); v) laudo de exame químico-toxicológico definitivo para cocaína (fls. 132/134); vi) laudo de exame químico-toxicológico definitivo para tetrahydrocannabinol (THC) (fls. 135/137); vii) laudo pericial em aparelho celular (fls. 183/190 e 212/259).

A autoria também é certa, conforme se depreende da prova oral colhida.

A Testemunha/CPM Wesley Brito Melinshy disse que já tinham informações de que naquele local havia tráfico de drogas. Outros moradores já tinham denunciado. No dia, viram um casal em frente à casa, réu e a namorada, tendo ele corrido para dentro do imóvel. Com ele, em busca pessoal, encontraram 1 porção de maconha. Perguntado, ele indicou que, no quarto, havia mais droga. Porém, também na geladeira, encontraram mais droga (maconha), pelo que ele acabou confessando a traficância. Encontraram tesoura, balança e outros petrechos. Tanto ele como os familiares são conhecidos por tráfico e aquele ponto era novo (de drogas). Não tinha abordado o réu até então (1 ano e 7 meses). O réu colaborou com a PM, indicando onde estava inicialmente a droga. A única pessoa que estava no local era a namorada, menor de idade, mas ele assumiu toda a propriedade da droga.

A Testemunha/CPM Luis Fernando Marques da Silva disse que estavam em patrulhamento quando viram o réu, sobre o qual já pesava denúncias de tráfico, o qual adentrou à residência quando os viu. Entraram na casa e com ele encontraram 1 porção de maconha. Perguntado se havia mais, disse que sim e que era para consumo. Porém,

conforme ele foi indicando os lugares, notaram que havia quantidade considerável (embaixo da cama e na geladeira). No começo, ele dizia ser para uso, mas diante da quantidade apreendida, ele disse que comercializava a droga na cidade e havia um outro parente que também fazia parte do comércio com ele.

Em seu interrogatório ANDERSON ADRIANO PIRES disse que a droga mencionada pegou para guardar para um amigo seu, o que fez por necessidade financeira. Ele daria por R\$ 100,00 para poder guardar a droga. Às vezes, o tal amigo também lhe dava pedaço de maconha para fumar. A tesoura era para dixer maconha. Atualmente trabalha em Jundiá, na Dexco, com CTPS digital. O réu mesmo não vendia e, quanto à residência, de fato morou muita gente que vendia droga e, por isso, a casa estava "queimada", pois já foi um ponto conhecido de droga. Foi ele quem alugou o imóvel. Na época, tinha 20 anos. A droga tinha chegado em sua casa há 1 semana. Hoje está com outra mulher. Sua mãe e irmãos foram assassinados aqui na região e, por isso, foi embora. Já abordou o réu outra ocasião e nada foi encontrado com ele. Nas buscas na casa, o réu tentou desviar no começo, mas conforme ele viu que os PMS procuraram com maior profundidade, ele colaborou.

Pois bem.

O conjunto probatório é robusto e conclusivo.

Os milicianos ouvidos foram coerentes e uníssonos, tanto na fase inquisitiva, quanto em Juízo, ao descreverem a ocorrência, inclusive quanto à quantidade de droga apreendida, bem como a dinâmica da apreensão da droga. Ora, urge destacar que o testemunho de policiais reveste-se de idoneidade e credibilidade suficientes a embasar, juntamente com os demais elementos de prova, o decreto condenatório. O simples fato de serem policiais não macula a prova oral de parcialidade, a não ser que haja prova em contrário nesse sentido, o que não ocorreu nos presentes autos.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

"Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de deporem e seus testemunhos não podem e não devem ser de modo algum, de forma apriorística, considerados suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial". (TJMG. Apelação Criminal nº 1.0349.08.020068-7/001. Relatora Des. MARIA CELESTE PORTO. 5ª Câmara Criminal. Julgado em 27/01/2009).

PROVA - Testemunha - Palavra de policiais quanto aos atos de diligência - Validade - Inexistência, nos autos, de qualquer evidência de má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público - Pedido revisional deferido em parte para reduzir a pena, fixado o regime inicial fechado (Revisão Criminal 99302019068600 - Monte Azul Paulista - Relator Antonio Sérgio Coelho de Oliveira - 16/04/2009 - Voto nº: 7929).

PROVA - Meios - Palavra de policial - Credibilidade - A só condição de policial não o torna suspeito - Depoimento colhido sob compromisso de dizer a verdade, como de qualquer testemunha, que deve ser examinado dentro de todo o conjunto probatório - Seria estranho o Estado selecionar pessoas para integrarem o quadro da Polícia e depois suspeitar delas quando agem no cumprimento do dever, ainda mais se inexistente interesse dos policiais em prejudicar o acusado - Entendimento - Recursos parcialmente providos (Apelação Criminal 99305025506900 - São Miguel Arcanjo 11ª Câmara de Direito Criminal - Relator José Odorico de Oliveira Passos - 17/09/2008 - Voto nº 16.395).

PROVA - Meios - Palavra de policial - Eficácia - Depoimentos de policiais, que efetuaram a prisão em flagrante, harmônicos, coerentes e firmes que ratificam os fatos narrados na denúncia e nenhuma razão tinham para incriminar os acusados, sem

motivo plausível ou causa justificável - Credibilidade - Recursos improvidos (Apelação Criminal 11391843000 - Barretos - 11ª Câmara do 6º Grupo as Seção Criminal - Relator Antônio Manssur 30/01/2008 - Voto nº 14.068).

Com efeito, não há nada nos autos que indique que os policiais quisessem incriminar falsamente o acusado, ao mencionarem que ele reconheceu que a droga encontrada na sua casa destinava-se ao tráfico.

Aliás, o próprio acusado reconheceu que guardava droga para terceiro, pelo que receberia R\$ 100,00 por fim de semana e, ainda, em maconha, já que também é usuário.

Assim, a quantidade de droga apreendida, a forma como estavam fracionadas e embaladas, o fato de já haver informações de que no local ocorria o tráfico de drogas, denotam que as substâncias apreendidas em poder do réu destinavam ao consumo de terceiro.

Passo, assim, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, vejo que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis, razão pela qual fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, sem agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento. Ante a primariedade do acusado e da ausência de indicativos de que ele integre organização criminosa ou se dedique à atividade ilícitas, vislumbro o cabimento da redução de pena, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, diminuindo em 2/3, perfazendo o montante de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no menor valor.

Pois Bem.

Na sessão do dia 23.6.2016, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. A discussão ocorreu no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, que foi deferido por maioria dos votos:

“O crime de tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda. Por conseguinte, não são exigíveis requisitos mais severos para o livramento condicional (Lei 11.343/2006, art. 44, parágrafo único) e tampouco incide a vedação à progressão de regime (Lei 8.072/1990, art. 2º, § 2º) para os casos em que aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, Lei 11.343/2006. Com base nessa orientação, o Plenário, por maioria, concedeu a ordem de “habeas corpus” para afastar a natureza hedionda de tal delito. No caso, os pacientes foram condenados pela prática de tráfico privilegiado, e a sentença de 1º grau afastara a natureza hedionda do delito. Posteriormente, o STJ entendera caracterizada a hediondez, o que impediria a concessão dos referidos benefícios v. Informativos 791 e 828. O Tribunal superou a jurisprudência que se firmara no sentido da hediondez do tráfico privilegiado. Sublinhou que a previsão legal seria indispensável para qualificar um crime como hediondo ou equiparado. Assim, a partir da leitura dos preceitos legais pertinentes, apenas as modalidades de tráfico de entorpecentes definidas no art. 33, “caput” e § 1º, da Lei 11.343/2006 seriam equiparadas a crimes hediondos. Entendeu que, para alguns delitos e seus autores, ainda que se tratasse de tipos mais gravemente apenados, deveriam ser reservadas algumas alternativas aos critérios gerais de punição. A legislação alusiva ao tráfico de drogas, por exemplo, prevê a possibilidade de redução da pena, desde que o agente seja primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre

organização criminosa. Essa previsão legal permitiria maior flexibilidade na gestão da política de drogas, pois autorizaria o juiz a avançar sobre a realidade pessoal de cada autor. Além disso, teria inegável importância do ponto de vista das decisões de política criminal.” (Informativo nº 831, STF. HC 118.833/MS, rel Min. Cármen Lúcia, 23.06.2016) (g.n.).

No mesmo sentido, o STJ, em 23.11.2016, por meio de sua 3ª Seção, por unanimidade, acolheu a tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, revisando o entendimento consolidado por ocasião do julgamento do REsp n. 1.329.088/RS - Tema 600, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC 118.533/MS. REVISÃO DO TEMA ANALISADO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 1.329.088/RS. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO Nº 512 DA SÚMULA DO STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do HC 118.533/MS, firmou entendimento de que apenas as modalidades de tráfico ilícito de drogas definidas no art. 33, caput e § 1º, da Lei nº 11.343/2006 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria “contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa.” (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016). 2. É sabido que os julgamentos proferidos pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão Pleno, não têm efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a proliferação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do tema analisado por este Sodalício sob o rito dos recursos repetitivos (Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1.329.088/RS - Tema 600). 3. Acolhimento da tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça (Petição nº 11.796 - DF (2016/0288056-2) RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ 23.11.2016).

Diante disso, como decorrência lógica, e revendo entendimento anterior, não deverá, portanto, incidir no caso o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, na redação dada pela Lei 11.464/07, que estipula como regra o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Isso porque, de forma incidental, o Plenário do STF já declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo, afirmando a possibilidade de o condenado por tráfico iniciar o cumprimento da pena em regime menos gravoso que o fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal (HC 111.840/ES, rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.06.2012).

Por fim, é cabível, em tráficos privilegiados, A DEPENDER DO QUANTUM DA PENA E DOS DEMAIS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CP, a substituição da sanção corporal por restritiva de direito. Ressalte-se que a Resolução 05/2012 do Senado Federal suspendeu a vedação de conversão em penas restritivas de direitos prevista no art. 44 da Lei de Drogas, declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS.

Em suma, não é possível hoje desconhecer que, notadamente a partir de decisões de seu Tribunal Pleno (HC 97.256/RS Rel. Ayres Britto j. 01.09.2010 m. v.; Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo 663.261/SP Rel. Luiz Fux j. 13.12.2012 m. v.), tal lição tem sido torrencialmente ministrada em julgados unânimes de ambas as Turmas julgadoras do Supremo Tribunal Federal, a quem, inclusive, incumbe o controle máximo da constitucionalidade em nosso País (2ª T HC 124.489/MG Rel. Teori Zavascki j. 10.03.2015; 1ª T RHC 123.080/BA Rel. Luiz Fux j. 21.10.2014; 1ª T HC 111.015/MS Rel. Luiz Fux j. 21.05.2013; 2ª T HC 115.174/RS Rel. Gilmar Mendes j. 02.04.2013; 1ª T HC 123.622/SP Rel. Luiz Fux j. 23.09.2014; 1ª T HC 120.876/SP Rel.

Luiz Fux j. 1ª T HC 120.663/SP Rel. Rosa Weber j. 29.04.2014; 2ª T RHC 120.247/MG Rel. Ricardo Lewandowski j. 25.02.2014; 1ª T HC 116.641/SP Rel. Marco Aurélio j. 25.02.2014; 2ª T HC 118.935/SP Rel. Ricardo Lewandowski j. 26.11.2013; 1ª T HC 115.508/SP Rel. Marco Aurélio j. 05.11.2013; 2ª T HC 115.350/MS Rel. Gilmar Mendes j. 29.10.2013; 2ª T HC 115.153/SP Rel. Gilmar Mendes j. 03.09.2013; 2ª T RHC 111.059/DF Rel. Ricardo Lewandowski j. 05.06.2012; 2ª T HC 111.247/MG Rel. Ricardo Lewandowski j. 27.03.2012).

Não diverso tem sido também o entendimento unânime adotado pelas duas Turmas de competência criminal do Superior Tribunal de Justiça (5ª T HC 298.792/SP Rel. Newton Trisotto j. 24.03.2015; 6ª T HC 213.412/ES Rel. Nefi Cordeiro j. 19.03.2015; 6ª T HC 187.874/MG Rel. Nefi Cordeiro j. 19.03.2015; 5ª T HC 308.380/SP Rel. Leopoldo de Arruda Raposo j. 05.03.2015; 5ª T HC 299.780/SP Rel. Newton Trisotto j. 03.03.2015; 6ª T HC 309.663/SP Rel. Nefi Cordeiro j. 03.03.2015; 5ª T HC 291.136/SP Rel. Felix Fischer j. 24.02.2015; 5ª T HC 307.913/SP Rel. Felix Fischer j. 24.02.2015; 5ª T HC 306.352/SP Rel. Felix Fischer j. 12.02.2015; 6ª T HC 307.489/SP Rel. Ericson Maranhão j. 12.02.2015; 5ª T HC 301.120/SP Rel. Newton Trisotto j. 10.02.2015; 5ª T HC 292.602/SP Rel. Newton Trisotto j. 10.02.2015; 5ª T HC 297.405/SP Rel. Newton Trisotto j. 10.02.2015; 6ª T HC 310.798/SP Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 03.02.2015; 6ª T AgRg no AREsp 436.420/DF Rel. Sebastião Reis Júnior j. 03.02.2015; 5ª T HC 304.439/SP Rel. Felix Fischer j. 03.02.2015). ASSIM, NO CASO EM ANÁLISE, ressalto que a pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial aberto, consoante art. 33º, § 2º, "c" do Código Penal (não reincidente e pena inferior a quatro anos).

Presentes os requisitos legais, substituindo somente a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena corporal, e prestação pecuniária, no importe de 1 (um) salário mínimo a ser destinado ao Fundo Municipal da Infância e Juventude, nos termos do § 2º, segunda parte, do art. 44, do CP.

Assim, a pena perfaz o montante de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no menor valor, substituída a pena corporal por PRD, nos termos retro.

III - Do Dispositivo

Ante ao exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ANDERSON ADRIANO PIRES, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, devendo cumprir a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no menor valor, substituída somente a pena corporal por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena corporal, e prestação pecuniária, no importe de 1 (um) salário mínimo a ser destinado ao Fundo Municipal da Infância e Juventude, nos termos do § 2º, segunda parte, do art. 44, do CP.

A considerar o quantum da pena ora fixado, bem como a primariedade do réu, CONCEDO-LHE o direito de recorrer em liberdade, até porque assim respondeu ao feito.

Custas na Forma da lei, visto que o réu é beneficiário da Lei nº. 1.060/50.

Expeça-se guia de recolhimento.

Deve a droga apreendida ser destruída se ainda não foi.

P.I.C.

Penápolis, 10 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA